

§2. Les modes de gestion des services publics

En principe, les personnes publiques responsables d'un SP sont libres de son mode de gestion (CE, 18 mars 1988, *Loupias* ; CE, 27 janvier 2011, *Commune de Ramatuelle*).

Une typologie des modes de gestion possible a notamment été dressée par l'arrêt du Conseil d'État *Commune d'Aix-en-Provence* du 6 avril 2007. Elle conduit à distinguer entre la gestion par la personne publique responsable du service (A) et la gestion déléguée à un tiers (B).

A. La gestion par la personne publique responsable

La gestion du service par la personne publique qui en est responsable peut être interne à la personne publique en question, ou externe via un tiers qu'elle contrôle quasiment comme l'un de ses services (au sens organique).

Dans le premier cas, on dit que le service est géré en régie (1). Dans le second cas, on dit qu'il s'agit d'une quasi-régie (2).

1. Les régies

La régie directe correspond au cas où le SP est géré par la personne publique responsable avec ses propres moyens humains, matériels et financiers.

C'est le mode de gestion obligatoire de certains SP, en raison de leur nature, comme les services régaliens (défense, fisc, police, etc.), ou la surveillance des élèves dans les cantines scolaires (si la restauration scolaire est un service déléguable, la surveillance relève elle de l'enseignement public ; v. CE, avis, 7 octobre 1986, n° 340609).

La gestion en régie est toutefois loin d'être cantonnée à ces seuls SP. On assiste même, ces dernières années, à une reprise en régie de services publics communaux qui avaient été délégués (transports urbains, distribution d'eau potable, etc.). On parle parfois de remunicipalisation pour désigner ce phénomène.

La gestion en régie peut toutefois prendre différentes formes. La gestion en régie directe peut ainsi être simple ou autonome. Dans ce dernier cas, le service compétent, tout en restant interne à la personne publique responsable, se voit doter d'une autonomie financière, voire d'une autonomie organique.

Par exemple, les régies municipales dotées de l'autonomie financière disposent d'un budget spécial annexé au budget de la commune, permettant que leur soit affecté les produits du service (art. L. 2221-11 CGCT), et sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur (art. L. 2221-14 CGCT).

A la régie directe, qu'elle soit simple ou autonome, s'ajoute la régie. Dans ce cas, la gestion du SP, n'est pas assurée par un service interne de la personne publique responsable, mais par un établissement public qu'elle a créé et contrôle, même s'il dispose d'une personnalité morale de droit public distincte.

C'est le cas par exemple d'« Eau de Paris », qui est à la fois dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Il s'agit d'un établissement public industriel et commercial créé par la ville pour assurer la gestion du service public de l'eau.

2. Les quasi-régies

On parle de quasi-régie lorsque le service, bien que géré par un tiers doté de la personnalité morale, autre qu'un établissement public, n'est toutefois que le simple prolongement administratif de la personne publique responsable.

Plus précisément, *« les collectivités publiques doivent être regardés comme gérant directement le SP si elles créent à cette fin un organisme dont l'objet statutaire exclusif est, sous réserve d'une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s'assurer du strict respect de son objet statutaire »* (CE Sect., 6 avril 2007, *Commune d'Aix-en-Provence*).

Deux critères sont donc indispensables pour que l'on puisse parler de quasi-régie.

Premièrement, que le contrôle exercé par le délégant sur le délégataire soit comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services.

Deuxièmement, que l'activité du délégataire soit principalement consacrée au délégant.

Ces critères sont issus de l'arrêt *Teckal* rendu par la CJUE le 18 novembre 1999. Ils ont depuis été consacrés par les textes de l'Union européenne transposés en droit français (notamment art. L. 2511-1 et suivants du code de la commande publique).

A priori, les sociétés publiques locales (SPL) au sens du droit français répondent à ces conditions.

B. La gestion déléguée à un véritable tiers

Si le délégataire est généralement une personne privée et si la délégation s'opère en principe par un contrat, la nature des délégataires de service public (1) et les formes de la délégation (2) sont toutefois plus diverses.

1. **La nature juridique du délégataire.**

Les délégataires de service public sont le plus souvent des personnes privées, comme des sociétés commerciales, des associations, des sociétés d'économie mixte (SEM), etc. Mais le tiers peut aussi être une personne morale de droit public.

Selon le CE, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que des personnes publiques soient candidates à la conclusion de contrats avec d'autres personnes publiques ayant pour objet la gestion d'un SP (CE Avis, 8 novembre 2000, *Sté Jean-Louis Bernard Consultants* ; CE, 16 octobre 2000, *Cie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau*).

De tels contrats ne pourront toutefois être légalement conclus avec des personnes publiques qu'à la condition que leur statut ne leur confère pas un avantage sur leurs concurrents privés.

En tout état de cause, délégataire privé ou public, le choix du délégataire n'est normalement pas discrétionnaire. Il doit le plus souvent intervenir après une mise en concurrence.

Ce n'est en revanche pas nécessaire lorsque la délégation est *in house*, c'est-à-dire lorsque le service est confié à un tiers correspondant aux conditions de la quasi-régie.

Il peut également en aller différemment lorsque la délégation de service public n'emprunte pas la forme d'un contrat, mais celle d'une habilitation unilatérale, par la loi ou par un acte administratif (v. CE Ass., 13 mai 1938, *Caisse primaire Aide et protection*).

Il en va ainsi des fédérations sportives délégataires, des ordres professionnels (des médecins, des avocats, des architectes, etc.), de Radio France, des hôpitaux publics, etc.

2. Les formes juridiques de délégation

Sauf texte contraire, la délégation d'un service public doit s'opérer par contrat (CE Sect., 6 avril 2007, *Commune d'Aix-en-Provence*).

Historiquement, on distinguait entre plusieurs formes de contrats de délégation de service public notamment :

- Le contrat de concession *stricto sensu* : il s'agissait d'un contrat par lequel la personne publique concédante charge le concessionnaire, non seulement de l'exploitation d'un service public, mais aussi de réaliser à ses frais les investissements préalables à la gestion du service, lesquels seront ensuite amortis au moyen des redevances versées par les usagers.
- Le contrat d'affermage : ce contrat se distinguait de la concession par le fait que les équipements nécessaires à l'exploitation du service sont fournis par la personne publique au délégataire, appelé ici fermier.
- Le contrat de régie intéressée : il se distingue de l'affermage dans la mesure où la rémunération du délégataire, ici le régisseur, est assurée par la collectivité, et non par les usagers.

Désormais, la délégation contractuelle d'un service public emprunte soit la forme d'une concession de service public (au sens large), soit d'un marché public de service (ce qui est plus rare).

Selon l'article L. 1121-1 du code de la commande publique, « *Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix* ».

Selon l'article L. 1111-1 du code de la commande publique, « *un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent* ».

Nous reviendrons sur la distinction entre les concessions et les marchés dans le chapitre du cours consacré aux contrats administratifs.

PERSONNEL - PR. MAISONNEUVE